

Hilgendorf y Valerius (Eric Hilgendorf / Brian Valerius)

Derecho Penal. Parte General — trad. de la 2.^a ed. alemana, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2017

Línea teórica: Teoría sistemático-racional de cuño alemán, orientada a la estructura del delito como concatenación de niveles (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad). Enfoque didáctico-panorámico con énfasis en esquemas de análisis y recomendaciones prácticas para exámenes jurídicos. Recepción moderada de teorías de imputación objetiva, dominio del hecho y filosofía de la pena de cuño Roxiniano.

Tesis central

El delito requiere necesariamente la realización de una acción típica y antijurídica cometida culpablemente. La culpabilidad presupone capacidad de culpabilidad (comprensión de la ilicitud y capacidad de conducción) y está limitada por el principio de coincidencia temporal: la capacidad debe existir al momento del hecho. El análisis sistemático por niveles es la herramienta esencial para evaluar la punibilidad en casos concretos.

Panorama

Manual introductorio de Derecho Penal Parte General que estructura el delito en sus niveles constitutivos (acción, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva/dolo, imputación objetiva, antijuridicidad con causas de justificación, culpabilidad). Hace pie en la teoría penal alemana de postgrado pero con vocación didáctica para estudiantes de primer semestre. Desarrolla extensamente tentativa, autoría y participación, delitos de omisión, imprudencia, y teoría del error. Incluye referencias a jurisprudencia y juristas alemanes de referencia.

Postura en la teoría del delito

Acción

Acción entendida como conducta humana voluntaria que puede ser comisión (hacer activo) u omisión (no hacer cuando había un deber). Se rechazan teorías de acción puramente psicológicas o causales, considerando el concepto de acción como elemento de vinculación entre sujeto y situación típica. En los delitos de omisión impropia se exige posición de garante (§ 13 StGB).

Tipicidad objetiva

Subsunción del hecho concreto bajo los elementos descriptivos del tipo penal. La causalidad se rige por la teoría de la condición (equivalencia de condiciones): toda condición que no pudiera ser mentalmente suprimida sin que desapareciera el resultado es causa del mismo. Se discuten casos especiales (cursos causales improbables, sobrecausas). El tipo objetivo requiere que se cumplan todos los elementos positivos del tipo (acción, objeto, resultado si lo hay).

Imputación objetiva

Teoría que va más allá de la causalidad fáctica: vincula el resultado típico con la acción del autor mediante criterios de imputación (relación de riesgo, ámbito de protección de la norma, fin de protección). No todo resultado causalmente conectado es objetivamente imputable; se requiere que el resultado sea expresión del

riesgo prohibido y que se encuentre dentro del ámbito de protección de la norma penal violada.

Tipo subjetivo · Dolo

El dolo requiere conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. Se distinguen elementos intelectual (conocimiento de las circunstancias típicas) y volitivo (voluntad de realizarlas). Se reconocen dolo directo de primer grado (intención directa), dolo directo de segundo grado (necesidad concurrente) y dolo eventual (aceptación del resultado como posible). No es necesario motivo alguno para el dolo.

Error de tipo

Error sobre circunstancias de hecho que integran el tipo objetivo excluye el dolo y, por regla, también la imprudencia (error de tipo vencible). Solo en delitos que admiten comisión imprudente entra en consideración esta forma de punibilidad. Error sobre la identidad de la persona o del objeto (error in persona vel obiecto) y aberratio ictus se tratan como especificidades que afectan la realización típica.

Antijuridicidad

Una conducta típica es antijurídica cuando no concurre causa de justificación. Se reconocen: legítima defensa (frente a ataque injusto), estado de necesidad justificante (preservación de bien jurídico propio o ajeno de peligro), consentimiento del titular (cuando disponible y sin vulneración de buenas costumbres), autorización legal (derecho de detención, corrección parental). El consentimiento presunto es admisible subsidiariamente y el consentimiento hipotético se discute crecientemente en intervenciones médicas.

Culpabilidad

Reproche personal por la actitud de ánimo censurable manifestada en el hecho antijurídico. Requiere capacidad de culpabilidad: comprensión de la ilicitud del hecho y capacidad de conducirse conforme a esa comprensión. El § 19 StGB excluye a menores de 14 años; los §§ 20-21 rigen trastornos psíquicos, debilidad mental y embriaguez. La culpabilidad está limitada por el principio de coincidencia: debe existir al momento del hecho.

Error de prohibición

Error sobre la ilicitud del hecho (no sobre circunstancias de hecho sino sobre la permisión legal). Error de prohibición vencible reduce la pena (culpabilidad disminuida); error invencible la excluye. Se discuten cuatro teorías sobre el error en las circunstancias de hecho de la justificación: teoría de elementos negativos del tipo, teoría del dolo, teoría estricta de culpabilidad, teoría limitada de culpabilidad (esta última probablemente dominante).

Tentativa

Punible el acto que comienza la ejecución inmediata de un delito si no se alcanza su consumación. Requiere decisión al hecho (representación concreta y voluntad de realizar el tipo), ponerse inmediatamente a ejecutar (superación de estadio preparatorio) y no consumación. El desistimiento voluntario excluye pena en tentativa inacabada; en tentativa acabada solo si se impide la consumación.

Autoría y participación

Distinción entre autoría y participación según teoría del dominio del hecho (probablemente dominante): autor es quien tiene el dominio del hecho, participante quien facilita sin tener ese dominio. Se reconocen autoría directa (realización típica personal), autoría mediata (actuación a través de otro sin capacidad culpable),

coautoría (acuerdo previo y ejecución conjunta). Participación comprende instigación y complicidad con requisitos diversos. Accesoriedad limitada: la participación es punible aunque el autor sea imputable.

Posturas en debates clave

- **Concepto de acción y teorías rivales.** Se reconocen múltiples teorías (causal, final, social) pero el manual no opta por una única, sino que opera con una noción intuitiva de acción como conducta voluntaria. La acción es punto de conexión necesario pero su definición exacta queda abierta a debate. (S4, A y B; n.m. 49-51)
- **Teoría de la imputación objetiva vs. causalidad pura.** Se supera la simple teoría de la equivalencia de condiciones exigiendo que el resultado esté dentro del ámbito de protección de la norma y sea manifestación del riesgo prohibido. Esto reduce significativamente los casos de responsabilidad comparado con criterios puramente causales. (S4, C; n.m. 63-70)
- **Dolo eventual y su tratamiento procesal.** Se reconoce el dolo eventual como auténtico dolo (no se sigue la teoría de la representación) pero se advierte sobre las dificultades probatorias de establecer la intención del autor de aceptar el riesgo. Se ofrecen distinciones prácticas para exámenes jurídicos. (S4, C, II; n.m. 74-86)
- **Consentimiento vs. acuerdo excluyente del tipo.** Distinta la función: el consentimiento excluye antijuridicidad cuando procede; el acuerdo excluyente del tipo (cuando la redacción típica lo permite: libertad, domicilio) evita ya la tipicidad. Esto tiene consecuencias en materia de error: solo en consentimiento son relevantes vicios de la voluntad. (S5, C, I; n.m. 109-114)
- **Culpabilidad disminuida por embriaguez y valores de concentración de alcohol.** A partir de 2,0% de BAC se presume culpabilidad disminuida; a partir de 3,0% se presume incapacidad. Pero no son límites automáticos: se requiere evaluación de conjunto considerando tolerancia individual, gravedad del delito, pérdida de consciencia. En delitos de acción por omisión (conducción) estos valores aumentan 10%. (S6, B, I; n.m. 10)
- **Actio libera in causa (acción libre en la causa) y sus modelos.** Se exponen tres modelos (excepción, ampliación, tipo/adelantamiento) sin adherencia definitiva. El texto critica el modelo de ampliación por vulneración del texto legal y el de tipo por adelantamiento excesivo del comienzo de tentativa. El BGH rechaza la aplicación en delitos de propia mano (conducción). Esta es una de las construcciones más discutidas de la teoría alemana. (S6, B, II; n.m. 11-28)
- **Dominio del hecho vs. teoría subjetiva en delimitación autoría-participación.** Se reconoce la teoría del dominio del hecho como probablemente dominante en doctrina alemana: autor es quien tiene dominio sobre el hecho concreto. Se mencionan críticas desde teorías subjetivas pero sin adherencia exclusiva. Esto es crucial en coautoría (exige acuerdo previo y ejecución conjunta). (S9, A, II; n.m. 32-42)
- **Tentativa de instigación y actos preparatorios del § 30 StGB.** La tentativa de instigación es punible según § 30 I StGB cuando el instigador persuade de modo inequívoco al otro. Los actos preparatorios (declararse dispuesto, aceptar ofrecimiento, ponerse de acuerdo para crimen) son punibles según § 30 II StGB como innovación político-criminal alemana. Se discute extensión y límites. (S10, F; n.m. 256-264)

Glosario

- **Culpabilidad (Schuld):** Reproche personal dirigido al autor por su actitud de ánimo censurable manifestada en la comisión de un hecho ilícito. Presupone capacidad de culpabilidad (comprensión de ilicitud y capacidad de conducción) y está limitada por el principio de coincidencia temporal. Fundamento y límite de la pena según § 46 StGB.
- **Imputación objetiva (objektive Zurechnung):** Criterio de atribución del resultado típico a la conducta más allá de la causalidad. Exige que el resultado sea manifestación del riesgo prohibido (relación de riesgo) y que se encuentre dentro del ámbito de protección de la norma penal (fin de protección). Supera la

teoría de equivalencia de condiciones.

- **Posición de garante (Garantenstellung):** Situación jurídica que genera en ciertos sujetos el deber de velar porque no se produzca un resultado típico, de modo que su omisión puede constituir delito impropio de omisión. Existen garantes de protección (padres de menor) y garantes de supervisión (médicos, custodios).
- **Dolo (Vorsatz):** Voluntad consciente de realizar los elementos del tipo objetivo. Requiere conocimiento de las circunstancias típicas (elemento intelectual) y voluntad de realizarlas (elemento volitivo). Se reconocen grados: dolo directo de primer grado (intención), dolo directo de segundo grado (necesidad), dolo eventual (aceptación del riesgo).
- **Causa de justificación (Rechtfertigungsgrund):** Circunstancia que, aunque el hecho sea típico y culpable, lo hace lícito y no punible. Incluye legítima defensa, estado de necesidad justificante, consentimiento del titular (si disponible), derecho de detención, corrección parental. El consentimiento presunto es admisible cuando no puede consultarse al titular.
- **Error de prohibición (Verbotsirrtum):** Error sobre la ilicitud de la conducta (no sobre circunstancias de hecho). Si es vencible, reduce la pena (culpabilidad disminuida); si es invencible, la excluye. Se discute si afecta el dolo o solo la culpabilidad (teorías de elementos negativos vs. teoría del dolo).
- **Principio de coincidencia (Konkurrenzprinzip):** Exigencia de que la capacidad de culpabilidad debe existir al momento del hecho, no antes ni después. Fundamental para rechazar construcciones como la actio libera in causa que pretenden castigar hechos cometidos sin culpabilidad apelando a culpabilidad anterior.
- **Dominio del hecho (Tatherrschaft):** Criterio de atribución de autoría: es autor quien tiene control sobre el decurso fáctico y puede decidir realizarlo u omitirlo. Se distingue de participación (instigación, complicidad) en que el participante no tiene tal dominio. Teoría probablemente dominante en Alemania.

Mapa de capítulos

§ 1. Introducción 1-21

Ubicación del Derecho Penal (material vs. procesal). Teorías de la pena: absolutas (retribución), relativas (prevención general y especial), unión. Principios fundamentales: legalidad (nullum crimen sine lege), culpabilidad (nulla poena sine culpa), duda (in dubio pro reo), última ratio, del hecho. Reglas de interpretación canónicas (gramatical, histórica, sistemática, teleológica). Clasificación de delitos (comisión/omisión, dolosos/imprudentes, generales/especiales/propia mano, lesión/peligro, resultado/actividad, estado/permanentes, crímenes/delitos).

§ 2. Ámbito de validez del Derecho Penal 23-33

Validez espacial: principio de territorialidad (§ 3), principio de personalidad activa y pasiva (§§ 5, 7), principio de protección del Estado (§ 5), principio de jurisdicción universal (§ 6). Validez temporal: determinación de pena por ley vigente al momento del hecho; ley más benigna si se modifica antes de sentencia; leyes transitorias. Momento del hecho según § 8: para cada participante individualmente (salvo coautoría donde comienza con primer coautor).

§ 3. El tratamiento de casos jurídico-penales 35-47

Subsunción de hechos concretos bajo normas generales. Estilo de dictamen jurídico: planteamiento de la cuestión (problematización), discusión de opiniones (con cita de autoridades), conclusión. Particularidades del análisis penal: estructura fija (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), esquemas de análisis, recomendaciones para exámenes.

§ 4. El delito de comisión doloso consumado: El tipo 49-86

Tipo objetivo: concepto de acción, causalidad (teoría de la equivalencia de condiciones, casos especiales), imputación objetiva (fundamentos, grupos de casos: relación de riesgo, ámbito de protección). Tipo subjetivo: dolo (fundamentos, elementos, clases: dolo directo I y II, dolo eventual), error de tipo. Condiciones objetivas de punibilidad (elementos que condicionan la punibilidad pero no la tipicidad).

§ 5. El delito de comisión doloso consumado: La antijuridicidad 87-127

Tipicidad vs. antijuridicidad. Causas de justificación: legítima defensa (situación, acción, elemento subjetivo), estado de necesidad justificante (situación, acción, elemento subjetivo), autotutela y derechos de necesidad civil, derecho de detención, corrección parental. Consentimiento (disponibilidad del bien, facultad de disposición, capacidad de consentir, ausencia de vicios, manifestación previa, no contrariedad a buenas costumbres, elemento subjetivo). Consentimiento presunto (subsidiariedad, consonancia con voluntad presunta). Consentimiento hipotético (aplicación creciente en medicina).

§ 6. El delito de comisión doloso consumado: La culpabilidad 129-147

Fundamentos de culpabilidad. Capacidad de culpabilidad: incapacidad de menores de 14 años (§ 19), incapacidad por trastorno psíquico grave (§ 20), culpabilidad disminuida (§ 21). Embriaguez: valores de BAC (2,0% culpabilidad disminuida, 3,0% incapacidad) y evaluación de conjunto. Actio libera in causa: modelos de excepción, ampliación y tipo; limitaciones jurisprudenciales (delitos de propia mano). Causas de exculpación: exceso en legítima defensa, estado de necesidad exculpante, inexigibilidad de la conducta adecuada a la norma.

§ 7. Medición de la pena y persecución penal 149-151

Principios generales de medición (culpabilidad como fundamento y límite, consideración de efectos futuros según § 46 StGB). Criterios de persecución penal: persecución obligatoria vs. facultativa, querella previa, autorización o mandato penal en casos especiales.

§ 8. Teoría del error 153-173

Error sobre circunstancias de hecho (fundamentos, exclusión de dolo, tipos especiales: error in persona vel obiecto, aberratio ictus). Error de prohibición (exclusión de culpabilidad si invencible, reducción si vencible). Errores sobre causas de justificación (teorías rivales sobre circs. de hecho de la permisión). Errores sobre presupuestos de persecución penal. Error sobre causas de exculpación. Errores sobre causas personales de exclusión de pena.

§ 9. Autoría y participación 175-219

Formas de participación. Delimitación autoría-participación: teoría del dominio del hecho vs. teoría subjetiva. Autoría: directa (realización personal), mediata (actuación a través de instrumento sin culpabilidad), coautoría (plan común y ejecución conjunta), actuar por otro (§ 14). Participación: instigación (tipo objetivo y subjetivo), complicidad (tipo objetivo y subjetivo), elementos personales especiales (§ 28 StGB).

§ 10. Tentativa 225-264

Fundamento punitivo (punición de actos previos sin consumación). Grados de realización del delito (actos preparatorios, tentativa, consumación). Análisis previo: decisión al hecho (representación concreta y voluntad). Ponerse inmediatamente (superación de estadio preparatorio, casos especiales). Desistimiento: en tentativa

inacabada (desistimiento voluntario excluye pena), en tentativa acabada (solo si se impide consumación), en participación múltiple (responsabilidad individual). Tentativa de participación: instigación tentada y actos preparatorios del § 30 II StGB.

§ 11. Delitos de omisión

265-291

Delitos propios e impropios de omisión. Tipo objetivo en delito impropio: omisión de la acción mandada (delimitación actuar/omitir, omitir), causalidad hipotética, posición de garante (garantes de protección y supervisión), cláusula de correspondencia. Tipo subjetivo (dolo), antijuridicidad, culpabilidad. Autoría y participación en delitos de omisión. Delitos de omisión impropio imprudente.

§ 12. Delitos imprudentes

293-314

Fundamento punitivo de la imprudencia. Clases de imprudencia (consciente e inconsciente). Tipo: violación del deber objetivo de cuidado, previsibilidad objetiva, imputación objetiva. Antijuridicidad, culpabilidad en imprudencia (exigencia de capacidad culpable). Autoría y participación. Delitos de omisión impropia imprudente. Combinaciones de dolo e imprudencia (tentativa calificada por resultado, tentativa de calificación por resultado).

§ 13. Concursos

317-326

Unidad de acción o pluralidad de acciones (criterio natural y jurídico). Concurso de leyes (especialidad, subsidiariedad, consunción). Unidad de hecho y pluralidad de hechos (principio ne bis in idem implícito).

§ 14. Dudas sobre la situación de hecho y determinación alternativa

329-331

Incerteza unilateral: aplicación del principio de duda (in dubio pro reo). Incerteza alternativa propia (no se puede determinar cuál de dos hechos ocurrió) e impropia (se sabe que ocurrió uno pero no cuál). Resoluciones alternativas en casos límite.

§ 15. Definiciones esenciales

332-341

Glosario final de términos clave: causalidad e imputación, dolo e imprudencia, antijuridicidad (legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento), culpabilidad, autoría y participación, tentativa, delitos de omisión. Tabla de definiciones accionables para referencia rápida.